InDret

Comentarios prácticos a la Ley de Enjuiciamiento Civil

Arts 1 a 5

Víctor Moreno Catena
Facultad de Derecho
Universidad Carlos III de Madrid

Luis Martín Contreras
Facultad de Derecho
Universidad Carlos III de Madrid

Working Paper nº: 206
Barcelona, abril de 2004
www.indret.com

Artículo 1. *Principio de legalidad procesal.*

En los procesos civiles, los tribunales y quienes ante ellos acudan e intervengan deberán actuar con arreglo a lo dispuesto en esta Ley.

El art. 1 de la LEC sienta el principio de legalidad procesal, exigiendo que todos cumplan sus disposiciones en el desarrollo de las actuaciones procesales civiles.

Que la primera disposición de la ley procesal sea precisamente proclamar su valor y ordenar el sometimiento de todos a sus disposiciones no deja de resultar importante en estos momentos, aunque haya sido una norma tradicional, pues el art. 1 de la vieja LEC de 1881 ya disponía que "el que haya de comparecer en juicio, tanto en asuntos de la jurisdicción contenciosa como de la voluntaria, deberá verificarlo ante el juez o tribunal que sea competente, y en la forma ordenada por esta Ley".

En efecto, es importante plantear la vigencia del principio de legalidad porque en ocasiones los jueces soslayan los preceptos de las leyes procesales, y porque el legislador aprueba leyes procesales incompletas, dejando lagunas que sólo con ingenio e inventiva pueden colmarse.

Este precepto mantiene intacto ese principio de legalidad que es esencial a la labor de los tribunales y que legitima su actuación en la medida en que sólo están sometidos a la ley, pero sin duda de ella son tributarios.

Por eso es conveniente prestar atención a las infracciones de la ley procesal y proceder a denunciarlas por las vías que la LEC proporciona. El rechazo de las denuncias de infracciones procesales porque no se hubiera llegado a producir una efectiva indefensión suele aparecer como fundamentación habitual en resoluciones judiciales, invocando entonces la salvaguarda de otros valores o principios constitucionales; pero lo cierto es que la ley procesal se ha vulnerado sin remedio. Sin embargo, contando con que la defensa de esos valores o principios es de suma importancia, no se puede realizar dejando a un lado la ley, porque en ese caso estaremos al propio tiempo socavando los pilares esenciales del Estado democrático de derecho.

Las disposiciones procesales no son normas de segundo orden, contrapuestas a las normas materiales, que se presentan como las relevantes para la tutela de los derechos subjetivos, ni se trata de disposiciones que entorpecen la labor de los tribunales, sino que representan una garantía básica para el ejercicio de la función jurisdiccional.

Es verdad que dentro de estas normas procesales se pueden encontrar algunas que encierran garantías esenciales, incluso de rango constitucional, como la que ordena el regular emplazamiento del demandado para que pueda ser oído; hay otras que fijan un trámite de menor relevancia, como las de aportación de copias, y algunas que señalan plazos de los llamados impropios, ordenando una actuación del juez. Esta distinción, que exige salvaguardar las

garantías esenciales del procedimiento, de audiencia y defensa, no autoriza a desconocer el valor del resto de preceptos procesales, que siempre encierran una garantía.

La infracción de las primeras se sanciona con la nulidad de pleno derecho, como sucede con la falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional, las actuaciones realizadas bajo violencia o intimidación, o sin la intervención preceptiva de abogado, o prescindiendo de normas esenciales del procedimiento, cuando se haya podido producir indefensión (art. 225 LEC, sin vigencia hasta tanto se reformen los arts. 238 y ss. LOPJ).

Los defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión, se deben hacer valer por medio de los recursos establecidos en la ley contra la resolución de que se trate (art. 227.1, sin vigencia hasta que se modifique la LOPJ). Se trata de una infracción que por afectar al derecho fundamental del art. 24.1 CE, cuando se hubiera producido, o el acto no pueda conseguir su propósito, también se impone la sanción de la nulidad.

Con un criterio de protección de las partes gravadas por una resolución, se dispone que las partes podrán interponer los recursos previstos en la ley contra las resoluciones judiciales que les afecten desfavorablemente (art. 448.1), de modo que su estimación acarreará la anulación de la resolución contraria a la ley. El recurso de reposición se presenta como el instrumento adecuado para resolver los quebrantamientos procesales, pues en él se debe expresar la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (art. 452, dejando de lado la exigencia de citar el concreto precepto procesal que se consideraba infringido como preveía el antiguo art. 377.I de la LEC de 1881); además el litigante debe haber denunciado la falta si hubiera tenido oportunidad procesal para ello, y pedido la subsanación si el defecto fuera sanable, pues en otro caso no prosperará el recurso de apelación (art. 459) ni el extraordinario por infracción procesal (art. 469.2).

Junto con estas infracciones de normas procesales contempla la LEC otros quebrantamientos a los que no se anuda consecuencia alguna, como el incumplimiento de algunos plazos, pues dispone el art. 229 que las actuaciones judiciales realizadas fuera del tiempo establecido sólo podrán anularse si lo impusiere la naturaleza del término o plazo.

El sometimiento del juez a la ley no sólo le impide así que pueda obviar las leyes procesales y acudir sólo y directamente a la Constitución, sino que al propio tiempo exige al legislador que proporcione a los tribunales unos instrumentos que resulten suficientes y útiles para el ejercicio de la potestad jurisdiccional, desechando cláusulas abiertas, que exigen de una integración por parte del juez, pues de ese modo el propio legislador está permitiendo e incluso incitando a la "creatividad judicial" extralegal.

Artículo 2. *Aplicación en el tiempo de las normas procesales civiles.*

Salvo que otra cosa se establezca en disposiciones legales de Derecho transitorio, los asuntos que correspondan a los tribunales civiles se sustanciarán siempre por éstos con arreglo a las normas procesales vigentes, que nunca serán retroactivas.

La eficacia general de las normas jurídicas depende, en primer término, de una clara delimitación de su ámbito temporal y espacial. En este sentido, los principios de legalidad y seguridad jurídica exigen conocer con precisión qué normas rigen en cada momento, y cuál es el ámbito espacial en el que han de ser aplicadas. Esta exigencia cobra especial importancia en el orden procesal, pues aquí la vigencia de los instrumentos del procedimiento y el ámbito de actuación de los tribunales no deben ofrecer ninguna duda.

La LEC dedica siete disposiciones transitorias a regular el inexcusable régimen que han de seguir las situaciones procesales subsistentes a su entrada en vigor, y consagra un precepto con vocación general y de naturaleza garantista, el art. 2, a la aplicación en el tiempo de las normas procesales civiles, en el que se concreta el principio constitucional de irretroactividad, establecido como regla general y sólo susceptible de excepción por las disposiciones de Derecho transitorio.

Mantiene la LEC en su art. 2 el principio general de irretroactividad en la aplicación de las normas procesales. Por tanto, esta ley será siempre aplicada a los hechos y situaciones procesales futuras, entendiéndose por tales los procedimientos iniciados a partir del 8 de enero de 2001, con independencia de que las situaciones o relaciones jurídicas de derecho material que puedan dar lugar al proceso hayan nacido o hubieran sido constituidas durante el período de vigencia de la vieja ley. Ello resuelve el problema de los derechos materiales adquiridos, cuya proyección procesal es independiente del momento en que dichos derechos nacieron o fueron constituidos.

Las siete Disposiciones transitorias de la LEC contienen otros tantos puntos de referencia que marcan el fin de las viejas normas procesales en los procedimientos en curso. Dicho régimen únicamente permite agotar, conforme a la LEC de 1881, la tramitación de los procedimientos que se encuentren en fase de recurso de casación (disp. trans. cuarta), y de los juicios ejecutivos en que se hubiera dado comienzo al procedimiento de apremio (disp. trans. quinta). Una vez en vigor la LEC sus disposiciones normativas se aplican automáticamente al régimen de recursos contra resoluciones interlocutorias cualquiera que sea el estado del procedimiento (disp. trans. primera), al proceso de ejecución aunque ya se hubieran iniciado las actuaciones ejecutivas, y a las medidas cautelares que pudieran interesarse en el curso del procedimiento, pudiendo solicitar la revisión de aquéllas ya adoptadas conforme a la normativa derogada. Además, las normas derogadas sólo podrán extender su vigencia hasta que concluya la instancia en tramitación, rigiendo desde entonces la nueva LEC para la segunda instancia o la casación (disp. trans. tercera). En cualquier caso, siempre será posible interesar la ejecución provisional aunque la resolución haya sido adoptada en la instancia correspondiente conforme a las normas de la antigua ley procesal civil (disp. trans. segunda, tercera y cuarta).

Artículo 3. *Ámbito territorial de las normas procesales civiles.*

Con las solas excepciones que puedan prever los Tratados y Convenios internacionales, los procesos civiles que se sigan en el territorio nacional se regirán únicamente por las normas procesales españolas.

El art. 3 de la LEC consagra, como principio general, la regla de que el proceso se rige por la ley del lugar donde se sigue. Se trata de un principio clásico, de naturaleza eminentemente procesal, que sin embargo no se recogía en la antigua LEC sino en el art. 8.2 CC, según el cual «las leyes procesales españolas serán las únicas aplicables a las actuaciones que se sustancien en territorio español, sin perjuicio de las remisiones que las mismas puedan hacer a las leyes extranjeras, respecto a los actos procesales que hayan de realizarse en España». Con acierto sistemático, la nueva LEC ha derogado el art. 8.2 CC para incluir, dentro de la regulación procesal civil, la norma que disciplina el ámbito territorial de aplicación de las normas procesales civiles.

Pueden identificarse tres razones fundamentales que justifican la utilidad del principio *lex fori regit processum* (CALVO CARAVACA). En primer término, es una regla avalada por la lógica y la razón práctica, en virtud de la cual los tribunales de cada país aplicarán, como norma general y por mejor conocer, las leyes procesales nacionales para la tramitación de los litigios. En segundo lugar, favorece la seguridad jurídica, tanto en el desempeño correcto de la función jurisdiccional, como en la previsión y conocimiento de las normas procesales por las partes litigantes. En tercer lugar, encuentra acomodo en el principio de soberanía, una de cuyas manifestaciones se concreta en la potestad jurisdiccional, y en las normas que disciplinan su ejercicio.

Aun siendo el art. 3 sistemáticamente oportuno, y atendiendo a una regla general correcta, se advierten algunos defectos de fondo, provocados por una redacción demasiado escueta y poco precisa. El principal problema que plantea es la falta de un tratamiento bilateral que reconozca la aplicación de la *lex fori* para las actuaciones procesales a practicar en el extranjero, cuando sean interesadas por los jueces españoles. Si los jueces españoles disponen de libertad para aplicar normas procesales nacionales o extranjeras a las actuaciones interesadas por un juez extranjero que hayan de practicarse en nuestro país, debería permitirse, en justa correspondencia, que cuando un juez español interese la práctica de una diligencia en el extranjero, dicha diligencia pueda ajustarse a las normas procesales del país donde deba ser practicada, y no necesariamente a las normas españolas, como dispone el art. 3 LEC. De ahí que hubiera resultado conveniente permitir que ciertos actos de asistencia judicial internacional se llevaran a cabo con arreglo a la ley extranjera del Estado del juez colaborador (CALVO CARAVACA).

El principio de la *lex fori* no es sin embargo absoluto, por lo que caben excepciones a dicha regla, derivadas tanto de lo dispuesto en los Convenios Internacionales suscritos por España –única posibilidad que contempla el art. 3 LEC– como de normas generadas en el ordenamiento jurídico interno.

Las excepciones que excluyen la aplicación preferente de la ley procesal nacional a favor de normas procesales extranjeras, en virtud de Convenio Internacional o por previsiones contenidas en el derecho interno español no son pocas, ni fáciles de sistematizar.

Artículo 4. ***Carácter supletorio de la Ley de Enjuiciamiento Civil.***

En defecto de disposiciones en las leyes que regulan los procesos penales, contencioso-administrativos, laborales y militares, serán de aplicación, a todos ellos, los preceptos de la presente Ley.

La LEC aparece como la disposición básica de nuestro ordenamiento jurídico procesal, capaz de integrar las lagunas normativas de las demás leyes que regulan la actividad jurisdiccional en otras ramas del Derecho.

Ya en la etapa de codificación en nuestro país a finales del siglo XIX y principios del XX, surge la idea de la supletoriedad como remedio lógico para las lagunas apreciadas en los textos legales. No obstante no se llegó a plasmar en ninguna norma este criterio de supremacía. La nueva LEC, introduce por primera vez ese carácter, en su art. 4, y parece remitir a la idea de un código procesal único, que pudiera servir para todos los órdenes jurisdiccionales, que se encargaría de regular materias como los presupuestos procesales, las resoluciones judiciales, las notificaciones, el auxilio judicial, los medios de impugnación, la ejecución, las vistas, etc., y que sería complementado por un texto reducido para las especificidades de cada una de las demás ramas del proceso.

El art. 4 LEC surgiría así con una clara vocación de servir de "norma modelo", pues proclama la supletoriedad de manera expresa, de forma que junto a los textos procesales de cada una de las leyes de esa naturaleza se establece un texto de referencia, no solamente para los casos de laguna legislativa, sino como mecanismo habitual de complementación a falta de regulación específica. Es decir, pretende aglutinar en su regulación materias que, según su propia Exposición de Motivos, tienen naturaleza de procesales, pero que se encuentran reguladas en la LOPJ y que deberán ser excluidos de esta norma.

De manera mas estricta o limitada, puede en cambio considerarse que la nueva LEC no introduce novedad, sino que simplemente efectúa una compilación de lo ya contenido en las respectivas disposiciones finales o adicionales de las leyes procesales administrativa, laboral, o militar, que se remiten expresamente a ella como si de un auténtico código procesal se tratase, de modo que sea este texto procesal el que colme las lagunas que planteen las leyes reguladoras del procedimiento en cada uno de los distintos órdenes jurisdiccionales.

Sin embargo, en estos momentos la Ley Orgánica del Poder Judicial contiene una regulación procesal que no puede ser obviada, pues según el principio de jerarquía normativa, del art. 9 CE, los preceptos de una norma con rango de orgánica serán aplicables de manera directa respecto de aquellas otras de rango inferior que regulen la misma materia, lo cual es aplicable también a las procesales, sin que pueda servir de excusa el que las normas procesales no tendrán naturaleza orgánica aunque se hallen incluidas en una ley con este rango, como ha mantenido parte de la doctrina y el debate parlamentario sobre la vigente LEC se encargó de desautorizar.

La LEC, consciente de la vigencia de la LOPJ, pero con declarado deseo de reforma, recoge en su Exposición de Motivos, aptdo. V, y por tanto sin carácter normativo[1], esa aspiración de supletoriedad, propia de un "código modelo", aun a sabiendas de que será de aplicación aquella norma hasta que sea modificada y se remitan sus preceptos a la propia ley procesal civil. Por su parte, cuando en la disposición derogatoria única, aptdo. 3, establece que *"se consideran derogadas…, cuantas normas se opongan o sean incompatibles con lo dispuesto en la presente Ley"*, hay que entender lo que sea contrario a las normas reguladas en la LEC, pero no lo que se encuentre regulado en norma con rango superior. Y es que la Exposición de Motivos fue redactada para un proyecto que iba a convertirse en ley con la consiguiente reforma de la LOPJ, pero que el juego de las mayorías parlamentarias malogró.

El legislador de 2000 tuvo la intención de modificar la LOPJ para excluir de ella determinados preceptos que consideraba de naturaleza simplemente procesal. Sin embargo, lo cierto es que el Parlamento exigió la mayoría necesaria para la modificación de una ley orgánica, y al no tenerla el partido promotor, las reformas no pudieron prosperar. Así, la disposición final decimoséptima, tuvo que habilitar un procedimiento transitorio para el recurso por infracción procesal hasta que se reforme la LOPJ.

Con esta situación es fácil concluir que la LOPJ en estos momentos es una norma de aplicación directa a todos los órdenes jurisdiccionales, y que, a pesar de lo que pudiera desprenderse de la EM de la LEC, en la actualidad en cada orden jurisdiccional será de aplicación de manera directa la correspondiente ley procesal que regule el procedimiento respectivo, y además la LOPJ, mientras que la ley procesal civil lo será sólo con carácter supletorio, no directo.

Dentro de los distintos preceptos que han de aplicarse de manera directa en los distintos órdenes jurisdiccionales, los tres casos más significados son los que se refieren a la regulación de la abstención y la recusación[2], a la nulidad de actuaciones[3], y a las propuestas de resolución[4].

---

[1] Sobre la falta de valor normativo de las Exp. de Motivos de las leyes, hasta el punto de no poder ser objeto directo de un recurso de inconstitucionalidad, STC 116/1999, de 17 de junio, que reitera lo ya declarado en las anteriores SSTC 36/1981, 150/1990, 212/1996, y 173/1998.

[2] Los artículos 217 a 228 de la LOPJ regulan sendos procedimientos de abstención y recusación, que serán de aplicación a todos los órdenes jurisdiccionales cuando se plantee alguna de estas cuestiones en el transcurso de cualquiera de los procedimientos. Esta regulación pretendió ser incorporada a la nueva LEC en la literalidad de la LOPJ, pero mientras no se consiga la reforma tantas veces citada, la norma a aplicar, no de manera supletoria sino directa, será la recogida en los citados preceptos de la LOPJ.

[3] Arts. 238 a 243 de la LOPJ, en su redacción dada por la Ley 5/1997, de 4 de diciembre. Nos encontramos ante un supuesto que, a pesar de los nefastos resultados, pues en modo alguno ha conseguido la reforma de 1997 disminuir el número de recursos de amparo, según se pretendía, sigue en vigor en la LOPJ, y su aplicación también será de forma directa en los distintos órdenes jurisdiccionales.

[4] Una vez más la EM vuelve a preconizar lo que después no se produjo, la supresión de las propuestas de resolución. El articulado nada regula sobre este tema, y el art. 290 LOPJ sigue estando vigente. En efecto, si nos atenemos al contenido de la EM de la LEC las propuestas de resolución habrían quedado derogadas. Pero no existe precepto alguno en la LEC en el que se establezca de manera expresa la supresión de las propuestas de resolución y, en caso de haberlo, iría en contra del principio constitucional de jerarquía normativa. Se podrá argumentar que, al no estar expresamente reguladas, quedan suprimidas, y así sería si no tuviéramos una norma que es de aplicación directa, por lo que hay que entender que las propuestas de providencia y de auto siguen

Con independencia de todo esto, la integración de las lagunas procesales deberá realizarse mediante la remisión al derecho supletorio, en concreto acudiendo a las disposiciones de la LEC, a través del cual se completa la heterointegración prevista en las principales leyes de enjuiciamiento, donde se hace una remisión expresa a la ley procesal civil en todo lo no previsto en ellas. Es el caso de la disposición final primera de la LJCA para el proceso administrativo, o de la adicional primera de la LPL para el proceso laboral. Por tanto, el art. 4 LEC aparece como una norma general de cierre que considera a esta ley derecho común supletorio de acuerdo con lo establecido por las otras leyes de enjuiciamiento.

De otra parte, este sistema de integración se completa con otras remisiones particulares a la disciplina de la LEC sobre una determinada materia o institución en el articulado de las distintas leyes de enjuiciamiento. Caso del art. 598 de la LECRIM, para los embargos, o de su art. 764.2 sobre contenido, presupuestos, y caución sustitutoria de las medidas cautelares o de la prestación de cauciones; del art. 984 para la ejecución de sentencia en cuanto a la responsabilidad civil; y del art. 996 LECRIM para las tercerías; del art. 60.4 LJCA en materia de prueba; del art. 14 LPL en cuestiones de competencia; o finalmente del art. 64.9 LORRPM). En puridad, estos casos de remisión particular a otra norma sobre una materia o institución no son supuestos en los que se supla una laguna, ya que ésta realmente no existe, dado que el legislador ha previsto la regulación del asunto o cuestión, aunque si bien de forma indirecta por remisión a otra norma.

En cambio en los casos en los que efectivamente exista una laguna sobre alguna cuestión será el momento de utilizar las remisiones generales a la LEC. La distinción tiene su trascendencia práctica, ya que en los casos de remisión particular no existirán problemas para aplicar las disposiciones a las que se ha remitido expresamente la ley, a pesar de posibles diferencias en los principios que rijan en cada orden jurisdiccional. En cambio, en las remisiones generales para suplir lagunas se pueden presentar problemas por las peculiaridades de cada una de las normas, tanto por parte de la remitente que presenta la laguna, como por parte de la remitida que contiene la solución para suplir el vacío normativo.

La problemática que suscitan estos distintos sistemas es diferente, pues mientras el primero supone una remisión amplísima, lo que permite la interpretación de quien pretende la supletoriedad, el último lo hace de manera concreta a un precepto determinado, sin que en este caso puedan plantearse problemas, pues el legislador de la norma de remisión ha conocido previamente el contenido del precepto al que se remite y, aun así, ha decidido no regular la situación concreta en el texto de remisión, para aplicar íntegramente el precepto de la norma supletoria.

Sin embargo, la experiencia demuestra que esto último no siempre es así, pues actualmente sucede que la norma supletoria ha sido redactada con posterioridad a las suplidas, sin que éstas se hayan adaptado a aquélla, lo que provoca más problemas que la remisión genérica al amparo de una teórica imposibilidad de interpretación.

---

estando en vigor en todos los órdenes jurisdiccionales y, mientras no se modifique la LOPJ, deberán ser usadas por los Secretarios judiciales para dar a los autos el impulso establecido en la ley.

Los mecanismos de integración pueden ser de dos tipos diferentes, de heterointegración o de autointegración[5]. En el primer caso es la supletoriedad la que se encarga de cubrir las lagunas del texto legal; en el de la autointegración es la técnica de la interpretación analógica dentro del mismo proceso la que se encarga de cubrir las ausencias de regulación específica.

Ambos mecanismos sirven para suplir la ausencia de regulación en supuestos concretos, pero la LEC en su art. 4 se ha decantado por la fórmula de la heterointegración. Sin embargo, este sistema hay que tomarlo con cautela en el caso de la LECRIM, en una doble vertiente; por una parte, en que todo texto legal debe como principio general ser autointegrado ante una eventual laguna, es decir, debe buscarse la analogía dentro de sus propios preceptos, y de su propia rama del Derecho, antes de acudir a cualquier otra analogía o supletoriedad y, por otra, que la cláusula de supletoriedad que se recoge en el art. 4 de la LEC ha de servir para suplir los vacíos legales de una rama del ordenamiento, pero nunca de la totalidad, pues en caso contrario se rompería ese carácter autointegrador de las distintas ramas del derecho que podría provocar desequilibrios difícilmente justificables a la luz de la Constitución.

Es así que las normas procesales tras la aprobación de la LEC se integran en un doble sistema: por una parte, el art. 4 establece una remisión genérica de todos los procesos de cualquier orden jurisdiccional, incluido el militar, a los preceptos de la LEC como norma supletoria. Establece así una cláusula de heterointegración que culmina las normas de esta naturaleza, ya citadas, recogidas en los distintos textos procesales, en los que de manera genérica se contienen normas de heterointegración. El art. 4 de la LEC es una cláusula general de cierre que configura a este texto legal como una norma de derecho común supletorio y como la culminación o compendio de las otras cláusulas de remisión. Pero esta cláusula de integración se complementa con otras específicas que se remiten a preceptos o trámites concretos de la LEC para llevar a cabo el desarrollo de una fase determinada del procedimiento.

Esta doble remisión suscita dos cuestiones. En primer lugar, la remisión genérica prevista en las distintas disposiciones y en el art. 4 de la LEC puede plantear algunos problemas sobre el alcance y eficacia de la remisión al derecho supletorio, y da pie a las numerosas interpretaciones analógicas. En cambio, las remisiones expresas recogen de manera indubitada la intención del legislador, por lo que en estos supuestos no se deja resquicio a la interpretación analógica, pues la ley de remisión establece cómo quiere que se interprete la supletoriedad en esos casos concretos.

En puridad en estos segundos supuestos no se puede hablar de lagunas legales, sino de supletoriedad querida por el legislador y, por lo tanto, de ahorro normativo, pues no se produce una laguna legal no querida por éste, sino una intencionada ausencia de regulación por considerar aplicable y suficiente la existente en la norma remitida.

Frente a lo que pudiera parecer, que los mayores problemas de acoplamiento de normas se dieran en los casos de supletoriedad genérica, en los supuestos de laguna legal, y derivados

[5] MORENO CATENA, V., en *El proceso civil, Doctrina, Jurisprudencia y Formularios,* Coord. Escribano Mora F., *v*ol. I, Ed. Tirant lo Blanch, Tratados, Valencia, 2001.

fundamentalmente de las genuinas características de cada proceso, según el orden jurisdiccional al que pertenezcan, sin embargo, en la práctica es en los casos de remisión concreta donde más problemas se suscitan, pues, como ya se dijo, en algunos casos las leyes procesales suplidas no se han adaptado a la posterior norma supletoria, de forma que en determinadas fases, probatoria en el contencioso-administrativo por ejemplo, la norma suplida no puede adaptarse a la supletoria, porque la primera se refiere a un proceso escrito y la segunda, la que ha de suplir a aquélla, a otro de naturaleza eminentemente oral, lo que provoca problemas a veces insalvables.

El art. 4 no es de fácil interpretación, pues *stricto sensu* considera a la LEC derecho supletorio común de todos los procesos judiciales ventilados ante la jurisdicción ordinaria y la militar, lo que plantea diversas dudas en relación con su alcance y con el concreto modo de realizar la integración de las normas procesales.

En primer lugar, respecto del alcance, resulta extraño que no se considere a los preceptos de la LEC como derecho común supletorio frente a los procedimientos constitucionales; y no resulta explicable esta omisión, especialmente cuando la propia LOTC, en su art. 80, prevé una remisión a la LOPJ y a la LEC en todo lo relativo a normas procesales, *vgr*., para el cómputo de plazos, forma de los actos procesales, comunicaciones, etc. Hay, pues, que entender vigente la remisión de la LOTC, a pesar de que la LEC no haya incluido en el art. 4 los procesos constitucionales.

En el polo opuesto se encuentra la remisión a la jurisdicción militar ya que, a pesar de estar incluida expresamente en el art. 4 de la LEC, la supletoriedad resulta en este caso prácticamente inoperante, por tratarse de una materia de naturaleza procesal fundamentalmente penal, y porque cuenta con una disposición específica de remisión supletoria a la Ley de Enjuiciamiento Criminal[6].

Por otra parte, existen también ciertas dudas sobre el alcance material de la remisión contenida en el art. 4, pues del tenor literal del precepto no se deduce si abarca toda clase de normas de la LEC, o si es una remisión exclusiva sólo para las normas procesales, es decir para aquellas que regulan las generalidades del proceso y procedimiento.

Estas dudas quedan resueltas a favor de considerar la LEC como derecho supletorio para todos los asuntos de naturaleza estrictamente procesal, relativos a cuestiones generales de todo proceso, tales como: cómputo de plazos; régimen de la nulidad de los actos procesales; presupuestos procesales, capacidad y legitimación de las partes; régimen de las resoluciones judiciales, etc. Es decir, el art. 4 es el instrumento que permite a la LEC adquirir el papel de norma común general en todas aquellas cuestiones que por su naturaleza sean comunes a todo proceso, aquellas que por su íntima conexión con la estructura básica y esencial de cualquier proceso, puedan ser utilizadas para suplir una laguna en un orden jurisdiccional diverso al civil, sin que interfieran los principios y características propias de ese orden jurisdiccional.

[6] La disp. adicional primera de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar, señala que la LECRIM y sus disposiciones complementarias serán aplicables a los procedimientos penales militares, que se regirán por dichas normas en cuanto no se regule y no se oponga a la presente ley.

Los límites de la supletoriedad debieran quedar meridianamente claros no obstante, pues no puede pretenderse que el art. 4 de la LEC sirva de factor habilitante para que las normas reguladoras de la rebeldía o de la carga de la prueba, por citar dos ejemplos concretos, puedan ser de aplicación ante posibles lagunas en la LECRIM, pues el proceso penal se rige por principios diferentes, de la misma manera que esa misma remisión no puede servir de forma genérica para suplir las posibles lagunas de la LJCA en materia de plazos de ejecución. Sin embargo, estos problemas quedan solventados cuando se trata de remisiones concretas, al margen de lo previsto en el art. 4 de la LEC, que se recogen en las otras leyes procesales y que ya han tenido en cuenta la naturaleza específica de cada proceso y han acudido a este sistema de supletoriedad por resultar aplicable, asumiendo intencionadamente las normas del proceso civil.

El Tribunal Supremo también se ha decantado desde antiguo por la supletoriedad de la LEC en el resto de los órdenes[7]. Posiblemente a causa de que sea históricamente el primer cuerpo procesal general, el más completo y el que en origen fue concebido para servir a la resolución de la mayoría de las cuestiones litigiosas, a pesar de que la LECRIM, aprobada un año después, partía con vocación de autosuficiencia, excepción hecha de la ejecución de la sentencia en sus aspectos civiles. De ahí que esta no cuente con una remisión genérica, sino de diferentes artículos que se remiten a la LEC para casos concretos.

Varios años después de su entrada en vigor, la Ley de Enjuiciamiento Civil sigue teniendo una asignatura pendiente, la aprobación de la reforma de la LOPJ en sus aspectos considerados procesales, y su incorporación a aquel texto procesal, lo que en la práctica convierte la supletoriedad, al menos en parte, en una mera declaración de intenciones. A pesar de lo cual ha acabado erigiéndose en un código procesal común, integrador de las lagunas que puedan surgir en la aplicación normativa en los procesos administrativo y social, y en menor medida, en lo penal y militar.

[7] *Vid.* STS-2ª, 26- feb-2000, sobre el art. 921 LEC/1881 y los intereses procesales; el ATS-3ª, 24-ene-2000, o la STS-4ª, 1-feb-2000.

Artículo 5. ***Clases de tutela jurisdiccional.***

1. Se podrá pretender de los tribunales la condena a determinada prestación, la declaración de la existencia de derechos y de situaciones jurídicas, la constitución, modificación o extinción de estas últimas, la ejecución, la adopción de medidas cautelares y cualquier otra clase de tutela que esté expresamente prevista por la ley.

2. Las pretensiones a que se refiere el apartado anterior se formularán ante el tribunal que sea competente y frente a los sujetos a quienes haya de afectar la decisión pretendida.

La rúbrica del art. 5 de la LEC parece que pudiera sintetizar la tutela que los jueces y tribunales puedan prestar cuando, en realidad, simplemente se ocupa de enumerar los posibles objetos de un proceso. Se produce en este precepto, por tanto, una identificación entre derecho de acción y pretensión ejercitada, de manera que el derecho de acción se configura en forma concreta, es decir como pretensión de tutela del derecho subjetivo. La consecuencia de esta configuración es la confusión entre derecho de acción y pretensión, lo que determina que sólo en el caso de que la pretensión planteada sea de las previstas en el ordenamiento pueda garantizarse el derecho de acción del sujeto actuante.

El art. 5 contiene una enumeración no taxativa de las posibles pretensiones a ejercitar ante un tribunal y constituye una evidente novedad en cuanto recoge legalmente la división de las pretensiones que doctrina y jurisprudencia ya manejaban durante el mandato de la LEC de 1881. Presenta cierto interés el que se deje abierta la posibilidad de otras pretensiones, siempre y cuando vengan reconocidas por una norma legal, pues permitirá en un futuro ampliar el contenido de eventuales actuaciones del juez a supuestos como el de la tutela preventiva de naturaleza satisfactiva ya previstos en otros ordenamientos (*injuctions* del derecho inglés o *rèfèrè* del derecho francés), pero todavía con difícil encaje en el nuestro.

El precepto se ocupa de las pretensiones de cognición, en concreto prevé la existencia de pretensiones meramente declarativas, de condena y constitutivas. Se caracterizan porque con ellas las partes procesales solicitarán del juez que, tras conocer del asunto en un proceso declarativo, dicte una resolución que ponga fin al conflicto entre las partes.

Las pretensiones meramente declarativas tienen por objeto conseguir que el juez dicte un pronunciamiento en el que se declare la existencia o inexistencia de un determinado derecho o de una concreta relación jurídica. En consecuencia, la finalidad perseguida es obtener certeza frente a situaciones jurídicamente discutidas o controvertidas; de ahí que presupuesto necesario para el triunfo de esta clase de pretensiones sea la existencia de un *contradictor* que ponga en tela de juicio la posición jurídica del actor, cuando se trate de una pretensión declarativa positiva, o bien

que la condición de *contradictor* la asuma el propio demandante cuando la pretensión sea negativa (*vgr.*, la acción negatoria de servidumbre). La necesidad de que el derecho o situación jurídica sean discutidos para un eventual triunfo de la pretensión mero declarativa se ha venido exigiendo por la jurisprudencia ya de antiguo (STS de 8 noviembre de 1994 (RJA 9317). En consecuencia, la legitimación para el planteamiento de pretensiones meramente declarativas derivará del hecho de ser titular de un derecho subjetivo o relación jurídica puesta en duda o discutida por alguien, o incluso del hecho de ostentar un interés legítimo para el esclarecimiento de la situación jurídica controvertida.

No debe existir inconveniente alguno, por su parte, para admitir pretensiones meramente declarativas de naturaleza negativa, es decir, aquellas en las que se solicita del juez que declare la inexistencia de un derecho o relación jurídica, a pesar de que el art. 5 expresamente sólo recoja la posibilidad de pretensiones declarativas de naturaleza positiva ("la declaración de la existencia de derechos y de situaciones jurídicas").

Con las pretensiones de condena se busca no sólo dar certidumbre a un derecho o situación jurídica controvertida, sino que además se solicita del juez la condena de la contraparte a realizar una prestación de dar, hacer o no hacer. De ahí que la pretensión de condena pueda conceptuarse como "mixta", pues contiene tanto una petición declarativa, dirigida al juez para que reconozca la existencia de un derecho controvertido, como, al tiempo, una petición de condena al deudor derivada de su falta de cumplimiento de la obligación dimanante del derecho declarado.

Una tercera posibilidad que puede revestir el objeto de un proceso declarativo son las conocidas como pretensiones constitutivas. En ellas la parte demandante dirige al juez una solicitud para que realice una modificación en la realidad jurídica existente mediante la constitución, modificación o extinción de un derecho, situación o relación jurídica. Estas pretensiones constitutivas, por tanto, se dirigen a producir un cambio jurídico en la realidad, creando un derecho donde antes no lo había, modificando una situación jurídica previa, o extinguiendo una relación con existencia anterior. La legitimación para el planteamiento de estas pretensiones se reconocerá a quienes ostenten la cualidad o el estado jurídico exigido por el derecho, relación o situación jurídica cuya modificación se pretende (*vgr.*, los cónyuges cuando se plantea una pretensión de nulidad matrimonial).

El art. 5 también reconoce la existencia de pretensiones cautelares, cuando permite que las partes puedan solicitar del órgano jurisdiccional la adopción de medidas cautelares. La principal característica de la pretensión cautelar es su instrumentalidad, ya que la adopción de las medidas cautelares se encaminará a garantizar la efectividad de un proceso principal en el que se discuta una pretensión de cognición, o más en concreto una pretensión de condena. Por tanto, en definitiva, la medida cautelar se dirige a garantizar la efectividad de una futura sentencia de condena.

Por último, el art. 5 prevé la existencia de pretensiones de ejecución, en las que el titular de un título de condena se dirige al juez solicitando la ejecución forzosa de la condena contenida en alguno de los títulos de ejecución previstos en el art. 517 de la misma LEC.

Finaliza este artículo disponiendo que las pretensiones a formular deberán plantearse frente a aquellos sujetos a los que haya de afectar la decisión que se solicita. Con ello no está haciendo otra cosa que reconocer que el objeto procesal, la pretensión, se conecta íntimamente con el derecho material en juego, hasta el punto que todos aquellos que puedan verse afectados habrán de ser emplazados para una válida constitución de la relación jurídica procesal. Por tanto, será la pretensión planteada por el demandante la que determinará la relación jurídica controvertida, y como consecuencia de esa inicial fijación del derecho material en juego, quedará determinada la persona (art. 10 LEC) o personas (art. 12.2 LEC) que habrán de integrar la parte pasiva del proceso.

La falta de integración de la parte demandada es de suma importancia, pues si así fuera se habrá producido una indefensión del sujeto no integrado en la *litis*, a pesar de lo cual no se verá afectado por la decisión. Una inadecuada integración de la parte demandada al inicio del proceso podrá suplirse mediante el instrumento de la intervención procesal (arts. 13 y 14 LEC), o en el trámite de la audiencia previa del juicio ordinario (art. 420 LEC).